

1501053-68.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... é a mera alusão à hediondez do tráfico para a negativa desses pleitos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento diverso, especialmente no caso do "tráfico privilegiado", como é a presente situação. No Habeas Corpus nº 118.53, entendeu-se que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501053-68.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Paulo Chelucci Júnior

Data da Audiência:

31/10/2022

Aos 31/10/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes, o réu Marcos Paulo Chelucci Júnior e a Defensora Pública Dra. Fabianne Carvalho Neves Xavier. Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais Vando Luis Barbosa e Gleber Lucarelli, em separado. Após, o acusado foi interrogado. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e interrogatório por se tratar de processo digital. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pela defesa foi requerida a juntada de documentos que comprovassem o trabalho do acusado. Pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Defiro a juntada dos documentos pela defesa. No mais, declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra a Defensora, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu está sendo acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A ação penal deve ser julgada improcedente. Como podemos claramente observar, não há nos autos conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado. O réu negou veementemente a prática do tráfico. Disse que à época trabalhava informalmente como feirante e havia acabado de terminar seu expediente. É usuário de drogas e estava no local com 7 pedras e 2 porções de K2 que se destinavam a seu próprio uso. Estava próximo a sua residência e apenas iria fazer uso do entorpecente. Nega que tenha

confessado os fatos em sede policial. Atualmente trabalha com registro em carteira (juntada nessa oportunidade). De outro lado, há apenas o relato dos policiais e a suposta confissão do réu em sede extrajudicial. Primeiro Excelência, o réu negou que tenha confessado os fatos em delegacia, fato esse alegado desde a audiência de custódia, na primeira oportunidade em que apresentado perante o juiz. Ademais, o fato de as testemunhas serem policiais não diminui o valor de suas declarações. Porém, as declarações dos policiais foram absolutamente vagas e em nada incriminaram o acusado. A primeira testemunha relatou que estavam em patrulhamento e que o local era objeto de denúncia de local em que praticado o tráfico. O acusado estava no local e demonstrou nervosismo ao avistar a viatura. Ao ser abordado tentou dispensar uma porção do entorpecente. Algumas outras porções foram localizadas em seu bolso juntamente com uma quantia em dinheiro. Ele confessou informalmente o tráfico alegando estar passando por dificuldades e apontou o local em que estavam acondicionados outras porções do entorpecente. Após o encontro dos entorpecentes realizaram outras buscas no local, infrutíferas. Ele estava sozinho no momento da abordagem. A segunda testemunha relatou que ao adentrar a via avistou o réu com um objeto nas mãos. Ele demonstrou nervosismo e na abordagem soltou o objeto no banco, que se constatou tratar-se de entorpecente. Ele confessou informalmente o tráfico e apontou onde estavam os demais entorpecentes. Não se recordou se as porções eram idênticas. Vê-se que nenhuma testemunha isenta foi ouvida, embora no local houvesse outras pessoas. Não foi presenciada a prática de atos que denotassem o comércio de drogas. Nenhuma outra informação que não a palavra policial foi trazida de ponto a justificar a procedência da ação. Diante do exposto, de rigor a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. No tocante à fixação da pena, requer-se: a) a fixação da pena base no mínimo legal, por serem favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais. Cumpre ressaltar que o acusado é ABSOLUTAMENTE PRIMÁRIO e foi detido com pouca quantidade e com apenas uma espécie de entorpecente (laudo de fls. 86/88 constatou apenas a presença de cocaína nas substâncias apreendidas); b) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativas; c) a aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, em razão do envolvimento ocasional da agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa, além do quanto já destacado no item 'a'; d) a fixação de regime inicial diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena possivelmente aplicado. Além disso, insuficiente é a mera alusão à hediondez do tráfico para a negativa desses pleitos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento diverso, especialmente no caso do "tráfico privilegiado", como é a presente situação. No Habeas Corpus nº 118.53, entendeu-se que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Ressaltou a Min. Carmem Lúcia, na ocasião, "A própria etiologia do crime privilegiado é incompatível com a natureza hedionda, pois não se pode ter por repulsivo, ignóbil, pavoroso, sórdido e provocador de uma grande indignação moral um delito derivado, brando e menor, cujo cuidado penal visa beneficiar o réu e atender à política pública sobre drogas vigente"; e) seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade". A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. MARCOS PAULO CHELUCCI JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo relata a denúncia, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 21hs, na Rua Vinte e Cinco de Janeiro, altura do numeral 11, Biritiba Mirim, Comarca de Mogi das Cruzes/SP, trazia consigo, para fins de mercancia, 46 (quarenta e seis) invólucros contendo 6,04g de cocaína na forma de crack e 03 (três) invólucros contendo 0,16g de cocaína, substâncias entorpecentes listadas na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F1 e F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil). Recebida a denúncia (fls. 61/62), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 104/105. Em audiência de instrução, foram

ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, pelo laudo de constatação provisória de fls. 11/14, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 86/88, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática do delito. Disse que é usuário de drogas e quando foi abordado pelos policiais trazia consigo apenas os entorpecentes que pretendia consumir, negando a intenção de comercializá-las. Ainda, negou ter confessado informalmente a prática do crime aos policiais, bem como negou que tivesse confessado na Delegacia de Polícia, afirmando que foi forçado a assinar um documento. Nada obstante, a versão exculpatória apresentada pelo acusado ficou completamente isolada. Não há dúvidas de que ele foi detido quando praticava tráfico de drogas. Inicialmente, destaco que o acusado admitiu integralmente a prática do delito na Delegacia de Polícia, porém inovou a sua versão em Juízo, afirmando que foi obrigado a assinar sem ler os documentos. Versão absolutamente vazia e desprovida de qualquer credibilidade. Ora, não há como se crer que, tendo sido forçado a assinar a sua confissão, teriam os policiais civis detalhado os fatos ocorridos, inclusive com a circunstância dele ser usuário de drogas. Em verdade, perdeu o acusado a oportunidade de admitir as imputações e demonstrar maturidade e responsabilidade acerca de sua conduta, elementos que demonstram o caráter do indivíduo. No caso em tela, os policiais apresentaram relato seguro e detalhado dos fatos. O policial militar Vando Luis Barbosa contou que estava em patrulhamento de rotina, quando avistou o acusado em atitude suspeita, razão pela qual decidiu abordá-lo. Disse que, em revista pessoal, localizaram em poder do réu certa quantidade de drogas, tendo ele, então, admitido a traficância, indicando o exato local em que estavam guardadas as demais drogas. Assim, relatou ter ido até o lugar indicado e lá encontrou mais drogas. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gleber Lucarelli. Nesse ponto, importa destacar que o depoimento prestado pelos policiais possui grande relevância, não havendo elementos a infirmar a veracidade de suas declarações. Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos. Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander: "Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander) No mesmo sentido é o entendimento do i. desembargador Ricardo Tucunduva: "Quanto ao que disseram os milicianos, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos." (TJSP; Apelação Criminal 1500434-55.2021.8.26.0558; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022) In casu, as provas produzidas em Juízo

são firmes e seguras ao apontar o acusado como sendo autor do delito de tráfico de drogas. De fato, a prática do delito ficou comprovada pela situação flagrancial retratada nos autos, a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão, a forma pela qual foi detido, isto é, em local notoriamente conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, comprovam a prática do delito de tráfico de drogas. Ressalto, ademais, que para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta a finalidade de guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, para caracterizar o crime em questão. O acusado não logrou comprovar por qualquer meio a versão por ele apresentada, não havendo sequer indícios de que os policiais pudessem estar o acusando falsamente. Aliás, seria verdadeiro absurdo crer que tanto os policiais militares quanto os policiais civis estivessem falseando com a verdade, apenas para imputar a alguém, que eles sequer conheciam e que sequer foi apresentado algum motivo razoável para que assim tivesse agido, a prática de um delito tão grave. Óbvio a falsidade da versão apresentada pelo réu. Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu é medida de rigor. Passo, então, à fixação da pena. Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, contudo deixo de reduzir a pena pois já fixada em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico a impossibilidade de seu reconhecimento, tendo em vista que a prova deixa claro que o réu não preenche os requisitos exigidos, pois foi detido em circunstâncias que evidenciam o seu anterior envolvimento com tráfico de drogas, isto é, em local conhecido pela alta incidência de tal delito e na posse de droga com notório poder lesivo à saúde. A própria conduta do acusado de imputar aos policiais militares e civis demonstra que se trata de alguém ligado à criminalidade. Não se trata de traficante eventual ou de pequeno traficante, a justificar a redução da pena como se pode ver. Nesse sentido, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo): "O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente 'não se dedique às atividades criminosas'. Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico" No mesmo sentido é o entendimento do i. Des. Sérgio Ribas (Apelação nº 0001509-68.2017.8.26.0616 - 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo): "Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas." Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou

mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena. Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra o i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 - 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo): "O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios". Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do CP. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar MARCOS PAULO CHELUCCI JUNIOR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa. Defiro o recurso em liberdade. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Por fim, determino o perdimento da quantia e objetos apreendidos em poder do acusado em favor da União. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". O acusado e sua defensora manifestam expressamente que desejam recorrer. Em seguida foi dito pelo MM. Juiz: "Recebo o recurso interposto pelo acusado, em seus regulares efeitos. Processem-no. Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de razões de apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões. Atualize histórico partes e cadastro de processo no SAJ. Posteriormente, cumpridas as determinações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - seção criminal". Pelo acusado foi informado que reside no endereço diligenciado às fls. 117 e informado telefone para contato: 11 97062-2351. Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais.

Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.